

裁判字號：臺北高等行政法院 98 年訴字第 2374 號判決

裁判日期：民國 99 年 03 月 11 日

裁判案由：違章建築

臺北高等行政法院判決

98年度訴字第2374號
99年3月4日辯論終結

原 告 甲○○
被 告 臺北縣政府違章建築拆除大隊
代 表 人 乙○○（代理大隊長）
訴訟代理人 丁○○
 丙○○

上列當事人間違章建築事件，原告提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

一、「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。有左列情形之一者，訴之變更或追加，應予准許：……四、應提起確認訴訟，誤為提起撤銷訴訟者。……」分別為行政訴訟法第111條第1項、第2項、第3項第4款所明定。又原告起訴時，行政處分之效力若已解消，且原告亦無可回復之法律利益，則主張處分作成有違法情事者，即應提起確認行政處分違法之訴。本件原告原起訴請求撤銷被告之行政處分，因爭執之系爭違建已經於民國(下同)97年12月22日拆除，據原告陳明在卷（見本院卷第112頁），並有被告違章建築結案通知單在卷可按（見本院卷第96頁），上開行政處分效力（即違章建築認定通知書）已因執行拆除而消滅，因原告認其對被告上揭違法處分有損害賠償請求之法律上利益，故變更確認原處分違法之聲明，被告未異議而為本案之言詞辯論，且原告主張之原因事實俱屬同一，是依上述行政訴訟法第111條規定原告此訴之變更，即無不合，應予准許，合先敘明。是被告主張本件行政處分已因執行完畢等原因而解消，原告所訴請撤銷之對象已不存在，原告提起本件撤銷訴訟已欠缺無法補正之訴訟要件，當不適法云云，容有誤解。

二、按「原告之訴，有左列各款情形之一者，行政法院應以裁定

駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正：「……」、「撤銷訴訟，原告於訴狀誤列被告機關者，準用第1項之規定。」，行政訴訟法第107條第1項、第2項定有明文。次按「經訴願程序之行政訴訟，其被告為左列機關：一、駁回訴願時之原處分機關。二、撤銷或變更原處分或決定時，為最後撤銷或變更之機關。」復為同法第24條所明定。次按「主管建築機關，在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」；「本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。」；「本法所稱建造，係指左列行為：一、新建：為新建造之建築物或將原建築物全部拆除而重行建築者。二、增建：於原建築物增加其面積或高度者。但以過廊與原建築物連接者，應視為新建。…四、修建：建築物之基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板、屋架或屋頂，其中任何一種有過半之修理或變更者。」；「建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。…」；「建築執照分左列四種：一、建造執照：建築物之新建、增建、改建及修建，應請領建造執照。…」；「違反第25條之規定者，依左列規定，分別處罰：一、擅自建造者，處以建築物造價千分之五十以下罰鍰，並勒令停工補辦手續；必要時得強制拆除其建築物。…」，建築法第2條第1項、第4條、第9條、第25條第1項前段、第28條第1款及第86條第1款各定有明文。再按「本辦法所稱之違章建築，為建築法適用地區內，依法應申請當地主管建築機關之審查許可並發給執照方能建築，而擅自建築之建築物。」；「直轄市、縣（市）主管建築機關，應於接到違章建築查報人員報告之日起5日內實施勘查，認定必須拆除者，應即拆除之。認定尚未構成拆除要件者，通知違建人於收到通知後30日內，依建築法第30條之規定補行申請執照。違建人之申請執照不合規定或逾期未補辦申領執照手續者，直轄市、縣（市）主管建築機關應拆除之。」違章建築處理辦法第2條及第5條各設有規定。被告96年8月29日北府工拆字第0960051355號公告：「公告建築法之違章建築處理業務有關本府權限事項委任本府違章建築拆除隊，以該隊名義執行之，並自中華民國96年9月12日起生效。」查本件97年11月14日北縣拆認字第0970049427號違章建築認定通知書認定該構造物係屬違章建築（下稱原處分）之作成機關為被告，原告起訴時誤列臺北縣政府為被告，嗣補正被告為臺北縣政府違章建築拆除大隊，並無不合，應予准許，合先敘明。

乙、實體方面：

一、事實概要：

訴外人江榮源（即原告之子）未經申請審查許可並發給建造執照，自行以數面鐵捲門封閉佔用臺北縣○○鎮○○路○○○

號建築物一樓騎樓，增建為高約3公尺，面積約20平方公尺構造物，經被告認有違反建築法第25條規定之情形，以原處分認定該構造物係屬違章建築。嗣原告表示已自行拆除系爭騎樓違建，經被告於同年12月22日至現場勘查，已達不堪使用標準，予以結案。原告不服原處分，遂向本院提起行政訴訟。

二、本件原告主張：

- (一)於79年間為配合政府規劃，開拓北二高打通東西方向通往中正機場的快速道路，使得交流道下的鶯桃路與中山路，會因車流量太大而塞車，因此須將道路拓寬，當時在鶯歌永靖活動中心召開徵收說明會，在場有臺北縣政府、公路局與鶯歌鎮公所之官員，會中官員同意鶯桃路與中山路騎樓可就地合法使用，居民才同意政府徵收土地。原告向被告及監察院陳訴，被告卻來函告知當時召開徵收說明之官員已退休或換人，無法提出證明，當時又未立文書，僅是口頭上說等語，推翻先前所為之承諾，分明為推託之詞，試問當時的會議無做成會議紀錄或報告？再則，當時召開之官員皆為公務人員，依法各機關皆留有個人之人事資料可查，可見被告並未查明真相，即回函回覆原告須依法強制執行拆除，致人民之權益於不顧。請被告提出當時之會議報告或記錄，或請當時承辦之官員當面與原告釐清事實真相。
- (二)85年間原告也為開罰單一事，到鶯歌鎮公所訴求，當時鶯歌鎮公所建設課課長為召開徵收說明會之官員之一，他很了解案情，特派鎮長室專員至三峽分局說明情形，准予騎樓合法使用不得再開立罰單，同為公家機關，何以為民服務之效率卻相差甚遠。
- (三)從80年道路拓寬完成起，原告在騎樓裝設鐵捲門，放置桌椅，經營小吃店維生，無奈樓上鄰居為可方便停放機車於騎樓，檢舉原告騎樓為違建，依照被告所訴，原告違反建築法第43條、建築技術規則設計施工編第57條及臺北縣騎樓及無遮簷人行道設置標準，依規留設之法定騎樓，依法不得構築鐵捲門妨礙行人通行。試問，何以檢舉人停放機車即不會妨礙行人通行，原告是否亦須每天請被告來拖吊機車？
- (四)原告於陳訴書中要求監察院調查被告有無涉及不法，從83年至今，鶯桃路上有幾件是被人亂檢舉，有幾件是被拆除又自行回復的，被告及監察院至今未回覆原告。再者，何以鶯桃路上之騎樓被拆除後，有些全數恢復可以不受法律規定，亦請被告一併說明此疑義。
- (五)綜上所述，原處分有違法之虞，為此，原告依據行政訴訟法第6條第1項規定，提起本件確認訴訟，並聲明求為判決：確認原處分違法，請被告將已拆除鐵捲門等部分恢復原狀。訴訟費用由被告負擔。

四、被告則以：

- (一)程序部分：

- 1.本件撤銷訴訟原告當事人不適格：查原處分之相對人為「江榮源」，被告並未對原告「甲○○」作成任何行政處分，原告與原處分上之建物所有人江榮源屬不同之權利義務主體，各具獨立人格，本案原告既非原處分之相對人，原告又未釋明與原處分有何法律上利害關係，遽行提起行政訴訟，應屬當事人不適格。
- 2.按「原告之訴，有左列各款情形之一者，行政法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正，審判長應定期先命補正：……十、起訴不合程式或不備其他要件者。」「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾3 個月不為決定，或延長訴願決定期間逾2 個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」「行政執行有下列情形之一者，執行機關應依職權或因義務人、利害關係人之申請終止執行：一、義務已全部履行或執行完畢者。二、行政處分或裁定經撤銷或變更確定者。三、義務之履行經證明為不可能者。」行政訴訟法第107 條第1 項第10款、第4 條第1 項及行政執行法第8 條第1 項分別定有明文。故行政處分存在為提起撤銷訴訟之訴訟要件之一，如行政處分已因執行完畢等原因而解消，則原告所訴請撤銷之對象已不存在，無從再予撤銷，本案系爭行政處分已因處分相對人江榮源自動履行完畢而解消，原告提起本件撤銷訴訟已欠缺無法補正之訴訟要件，當不適法。
- 3.關於原告訴之聲明二主張被告應將遭拆除之鐵捲門恢復原狀，並不適法：關於行政處分之執行所直接產生之侵害或違法狀態對於此一執行行政處分之事實行為，如欲排除該事實行為所造成之侵害，欲行使公法上結果除去請求權應對其執行所依據行政處分通知提出訴願後，依行政訴訟法第196 條規定於提起撤銷訴訟請求撤銷該違法行政處分，同時聲請行政法院判命原處分機關回復原狀，即所謂「執行結果除去請求權」。按原處分係課與處分相對人負有自行拆除系爭騎樓違建之義務，因該義務之履行不具有長期性，且履行後未存有持續性之法律狀態，當屬公法上一次性、履行後即消滅之義務，不具有救濟可能性及回復實益，應無從主張公法上結果除去請求權而提起撤銷訴訟。又原告既非原處分之相對人，且原處分已因訴外人江榮源自行履行完畢而解消，自與上開所述得提起撤銷訴訟、行使公法上結果除去請求權之訴訟要件不符，其起訴顯係欠缺保護必要，應予駁回。

(二)實體部分：

- 1.按建築法第4 條規定：「本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。」同法第9 條規定：「本法所稱建造，係指左列行為：一、新建：為新建造之建築物或將原

建築物全部拆除而重行建築者。二、增建：於原建建築物增加其面積或高度者。但以過廊與原建築物連接者，應視為新。三、改建：將建築物之一部份拆除，於原建築基地範圍內改造，而不增高或擴大面積者。四、修建：建築物之基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板、屋架或屋頂、其中任何一種有過半之修理或變更者。」、第25條前段規定：「建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。」、第86條第1款規定：「違反第25條之規定者，依左列規定，分別處罰：一、擅自建造者，處以建築物造價千分之五十以下罰鍰，並勒令停工補辦手續；必要時得強制拆除其建築物。」違章建築處理辦法第2條：「本辦法所稱之違章建築，為建築法適用地區內，依法應申請當地主管建築機關之審查許可並發給執照方能建築，而擅自建築之建築物。」建築法第43條第2項規定：建築物設有騎樓者，其地平面不得與鄰接之騎樓地平面高低不平。但因地勢關係，經直轄市、縣市主關機關核准者，不在此限。建築技術規則施工編第57條第2款規定：騎樓地面應與人行道齊平，無人行道者，應高於道路邊界處十公分至二十公分，表面鋪設應平整，不得裝置任何台階或障礙物……。臺北縣騎樓及無遮簷人行道設置標準第3條第2、3款亦規定：「騎樓地面應與人行道齊平……不得設置任何障礙物。」

2.建築物設有騎樓者，依據建築法第43條、建築技術規則設計施工編第57條及臺北縣騎樓及無遮簷人行道設置標準第3條規定，不得設置任何障礙物，原告主張恢復系爭騎樓鐵捲門違法佔用，顯無理由：查臺北縣○○鎮○○路○○○號建築物之土地建物查詢資料、建物測量成果圖，均記載有法定騎樓及位置標示，顯示本案合法建築物係為地上5層建築物且有法定騎樓，訴外人江榮源未經申請許可並發給執照，擅自於所有坐落鶯桃路437號1樓騎樓違法增建鐵捲門，違法占用騎樓空間使用，經被告派員實地勘查屬實，依法作成原處分。被告所屬人員於97年12月18日下午以電話連絡原告，原告則表示系爭騎樓違建已自行拆除，被告所屬人員於12月22日至現場勘查，已達不堪使用標準，故予以結案。準此，原處分並無不適法之處。

(三)綜上論述，原處分並無違誤等語，資為抗辯。並聲明求為判決駁回原告之訴、訴訟費用由原告負擔。

五、歸納兩造上述之主張，本件爭執之重點在於：原告提起本件確認訴訟，是否具有確認利益？原告合併請求恢復原狀，有無理由？本院判斷如下：

(一)按「確認行政處分無效及確認公法上法律關係成立或不成立之訴訟，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之。其確認已執行完畢或因其他事由而消滅之行政處分為違法之訴訟，亦同。」行政訴訟法第6條第1項有明文規定。

故提起確認之訴必須具有確認利益，即提起確認訴訟之原告必須係法律上地位或者權利有遭受侵害之危險，而能以確認之訴排除者始可，且該法律上利益值得保護為限。次按「利害關係人，係指違法行政處分之結果致其現已存在之權利或法律上之利益受影響者而言，若僅具經濟上、情感上或其他事實上之利害關係者則不屬之」改制前行政法院75年度判字第362 號判例意旨參照。

(二)經查，原處分之相對人係訴外人江榮源，並非原告，有原處分附卷可按(見本院卷第9 頁)。本院質之原告是基於何種身分提起本件行政訴訟？答稱：「那個房子是登記我兒子的名字，我兒子叫江榮源。(問：江榮源有沒有提起訴訟？有沒有提起訴願？)沒有。(問：房子是你兒子的，違建也是你兒子的？)對。(問：拆違建和你有什麼關係？)政府官員亂做，老百姓不能檢舉嗎？(問：房子和違建都是你兒子的，你什麼權利受損害？)來拆的時候很兇。」等語(見本院卷第112-113 頁)。則原告既非系爭違章建築之所有權人，亦非原處分之相對人，不致因原處分有權利或法律上利益受到侵害。原告嗣主張系爭鐵捲門等違章建築係其出資興建云云，惟未舉證以實其說，已難憑信，且依民法第811 條規定「動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。」，系爭鐵捲門等違章建築因附合為臺北縣○○鎮○○路○○○ 號建築物之重要成分，即由該不動產所有人江榮源取得所有權，原告仍無任何法律上利益或權利遭受原處分侵害之情事，自難謂係法律上之利害關係人。故原告並無訴請確認原處分違法之訴之利益，其提起本件確認訴訟，自屬不適格，應予駁回。其請求被告將已拆除鐵捲門等部分恢復原狀部分，亦失所據，為無理由，應併予駁回。

六、綜上，原告提起本件確認訴訟，訴請確認原處分違法，為當事人不適格，其請求判命被告將已拆除鐵捲門等部分恢復原狀，為無理由，均應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及陳述，核與判決結果不生影響，爰不逐一論列，原告請求本院至現場履勘，核無必要，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 3 月 11 日

臺北高等行政法院第七庭

審判長法 官 吳慧娟

法 官 畢乃俊

法 官 林惠瑜

上為正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 99 年 3 月 11 日
書記官 劉道文

資料來源：司法院法學資料檢索系統